Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
4ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacent4vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5077451-51.2023.8.21.0001/RS

AUTOR: VANESSA MADAIL RUAS

RÉU: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

SENTENÇA

Vistos etc.

VANESSA MADAIL RUAS ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor de **UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA**, alegando ser portadora de Linfoma de Hodgkin (CID 10 C81), necessitando fazer uso combinado dos medicamentos Bendamustina 90mg, Gencitabina 8000mg e Dexametasona 40mg por dois ciclos para controle e remissão da doença, mas a requerida negou cobertura justificando se tratar de prescrição para fármacos off-label. Ressaltou que a não utilização dos medicamentos coloca sua vida em risco e impossibilita a realização do transplante alogênico de medula óssea indispensável para consolidar a resposta almejada pelo tratamento. Requereu, em sede tutela de urgência, o fornecimento dos fármacos e, no mérito, a confirmação dos efeitos da tutela e condenação da requerida ao ressarcimento da quantia de R$ 6.000,00 já desembolsada para aquisição dos medicamentos.

Foi deferida a tutela postulada, determinando que a requerida forneça os medicamentos Bendamustina, Gencitabina e Dexametasona, na quantidade prescrita pelo médico, sob pena de multa diária (ev.8).

A requerida contestou, justificando a negativa de cobertura por se tratarem de medicamentos de caráter off-label, pois apesar de registrados na ANVISA, não se destinam para o tratamento do Linfoma de Hogdkin diagnosticado na autora. Discorreu acerca da ausência de violação ao dever de informação, sendo claro o contrato acerca da extensão da cobertura contratada e validade da cláusula limitadora de cobertura. Requereu a improcedência do pedido (ev.22).

Houve réplica (ev.26).

As partes não pretenderam a produção de outras provas.

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

Julgo o feito no estado em que se encontra, nos termos do artigo 355, inciso I do CPC, pois a matéria *sub judice* é de direito, sem necessidade de produção de outras provas.

É incontroversa a relação jurídica entre as partes, aplicando-se, no ponto, o artigo 374, III do CPC.

A atividade securitária está abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se verifica da leitura do artigo 3º, parágrafo 2º do diploma consumerista, *in verbis:*

> ...
>
> *§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.*

Ademais, tal entendimento encontra-se consubstanciado no texto da Súmula 469 do STJ, segundo a qual, "*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".*

Assim, aplicáveis ao presente caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, dentre elas, a inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência probatória da parte autora.

O relatório do médico hematologista Dr. Marcelo Eduardo Zanella Capra, CRM/RS 22834 (ev1, laudo8), comprova que a autora é portadora de Linfoma de Hodgkin (CID 10 C81) e a indispensabilidade do tratamento com as medicações Bendamustina 90mg, Gencitabina 8000mg e Dexametasona 40mg, vejamos:

PACIENTE

Vanessa Madail Ruas

CPF: 934.929.600-49

Atestado

Atesto que a paciente acima apresenta CID C81 - Linfoma Hodgkin desde 2007, refratário a diversos esquemas de quimioterapia, que inclui todos os aprovados no país, incluindo ABVD, ICE, DHAP, BEAM, radioterapia, IGEV, Brentuximab e Nivolumab. No momento, vinha em tratamento com Brentuximabe, enquanto se buscava doador para um transplante alogênico, única possibilidade de tratamento curativo. Ocorre que a doença progrediu, e foi identificado um doador compatível, porém para o transplante é necessário que a doença esteja em remissão.

Desta forma, considerando a literatura mundial, em casos de linfoma de Hodgkin refratários, uma droga que demonstrou bons resultados é a Bendamustina (literatura anexa), a qual é recomendada como opção terapêutica após 3 linhas de tratamento (o que é o caso da paciente) pela diretriz americana (EUA), o "National Comprehensive Câncer Network" - NCCN - um dos mais respeitados consensos do mundo. Esta droga está disponível no Brasil, porém para outras indicações (Linfoma Não Hodgkin e Leucemia Linfocítica Crônica), sendo portanto de uso "off label". Seu uso é já bem estabelecido nestes cenários e a droga é considerada segura e com boa chance de atingir o resultado esperado (remissão da doença), o que permitiria o tratamento curativo (transplante). Tal droga é utilizada em combinação, e, considerando a literatura disponível e os tratamentos utilizados, considero que o esquema Bendamustina, Gencitabina e Dexametasona (anexo) é o mais adequado para a paciente (literatura anexa)

Considerando os tratamentos já recebidos e o caráter ainda curativo para esta doença em paciente jovem, solicito o fornecimento da medicação em caráter "off label", dada a ausência de opções terapêuticas no cenário nacional, ausência de pesquisa clínica nesta condição que pudesse incluir a paciente e pelo risco de vida a qual a paciente está submetida caso não tenha a doença controlada para a realização do transplante.

À disposição para esclarecimentos.

01 de Maio de 2023

MARCELO EDUARDO ZANELLA CAPRA CRM-RS 22834

Hematologia E Hemoterapia (RQE: 13753), Clínica Médica (RQE: 16780)

É incontroverso que o contrato de plano de saúde do qual a autora é beneficiária possui cobertura para a doença que lhe acomete, qual seja, Linfoma Hodgkin (CID C81), mas a requerida negou cobertura para a medicação prescrita, justificando não constar na bula do medicamento a indicação para o quadro clínico da autora.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde fundamentada no fato de a doença do paciente não constar na bula do medicamento inserido no rol da ANS e prescrito pelo médico que ministra o tratamento, vejamos:

> *CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTOS PREVISTOS NO ROL DA ANS. TRATAMENTO "OFF-LABEL" INDICADO POR MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA DEVIDA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA DA DOENÇA DO CONSUMIDOR. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.*
> *1. **Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento inserido no rol da ANS prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso "off-label") (AgInt no AREsp 1.713.784/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/3/2021, DJe 7/4/2021).***
> *2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e revisão das cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).*
> *3. No caso concreto, para alterar o entendimento do Tribunal de origem, quanto à ocorrência do dano moral, além do referente à existência de previsão contratual de cobertura para a doença que atingiu o consumidor, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a revisão das cláusulas contratuais.*
> *4. Agravo interno a que se nega provimento.*
> *(AgInt no REsp 1919623/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 14/06/2021) (grifei).*

No mesmo norte, o Tribunal de Justiça do RS no julgamento da Apelação Cível nº 50666643120218210001, elucidou que o medicamento off label é fármaco com comercialização autorizada pela ANVISA e não pode ser confundido com o medicamento experimental, o qual não está aprovado para comercialização geral porque ainda dependente de testes, sendo o médico do paciente quem deve decidir se a situação de enfermidade está adequada ao tratamento com aquele medicamento.

Nesse sentido, transcrevo a decisão mencionada, *in verbis*:

> *APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO OFF LABEL. MEDICAMENTO QUE CONSTA NO ROL DE COBERTURA OBRIGATÓRIA DA ANS. ANTINEOPLÁSICO. LEVANTINIBE. NEGATIVA DE COBERTURA. DEVER DE COBERTURA RECONHECIDO. Trata-se de ação de obrigação de fazer, através da qual a parte autora, objetiva duas medicações (Nintedanibe - nome comercial OFEV - e Micofenolato de Mofetila- nome comercial CELLCEPT) e aplicações da medicação Rituximabe – nome comercial MABTHERA de 1000ml - a cada 06 meses, julgada procedente na origem. No caso a autora foi diagnosticada com pneumonia intersticial com achados autoimunes e prescrito o uso de duas medicações (Nintedanibe - nome comercial OFEV - e Micofenolato de Mofetila- nome comercial CELLCEPT) e aplicações da medicação Rituximabe – nome comercial MABTHERA de 1000ml - a cada 06 meses, ambulatorial, com duas aplicações num intervalo de 15 dias, e a requerida, ora agravante negou-se a fornecer cobertura sob o argumento de se tratar de medicamento off label. Assim, **é obrigatória a cobertura em casos pontuais cientificamente respaldados e sob a responsabilidade do médico assistente**, considerando que, diferentemente do medicamento experimental – em testes para o desenvolvimento e ainda não aprovado para comercialização em geral –, **o medicamento off label é fármaco com comercialização autorizada pela ANVISA e submetido ao Sistema Nacional de Farmacovigilância, cujo uso não fere as normas sanitárias, além de estar autorizado pelo Conselho Federal de Medicina.** Assim, o médico assistente é quem decidirá se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio, tornando inviável que a operadora do plano se negue a cobrir o tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula, considerando que representaria inegável ingerência na ciência médica, em prejuízo do paciente enfermo. Por oportuno ressalta-se que, não se desconhece que a medicação perquirida, se trata de medicação off label, no entanto tal recusa é indevida, considerando que é dever da operadora do plano de saúde de fornecer a medicação prescrita pelo médico, sendo ele off label, de uso domiciliar (home care), ou ainda, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade que seja objeto de cobertura pelo contrato (considerando o rol da ANS), como se vislumbra no caso telado, e devidamente prescrito pelo médico assistente do beneficiário. Considerando as regras e princípios do CDC, em especial no da interpretação mais favorável ao consumidor e no da boa-fé objetiva. Consoante recentes julgados do egrégio STJ, restou consolidado que é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da*

ANS (atual art.17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021). Assim, conclui-se que devem ser cobertos, pelos planos de saúde, a medicação antineoplásica indicada para o tratamento de saúde da parte autora, ademais ambas as medicações constam no rol de cobertura obrigatória da ANS - Resolução nº 465/2021. APELAÇÃO DESPROVIDA(Apelação Cível, Nº 50666643120218210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Redator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 03-06-2022).

E, no presente caso, o médico que assiste a autora foi categórico ao prescrever os medicamentos e indicar a sua indispensabilidade e urgência.

Ademais, a Segunda Sessão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.886.929 e REsp 1.889.704, por maioria de votos, definiu a controvérsia quanto à natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, se taxativo ou exemplificativo, concluindo ser taxativo, de forma que as operadoras do plano de saúde não estão obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista.

Não obstante isso, a Corte Superior fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor.

Posteriormente, a Lei nº 14.454, sancionada em 21/09/2022, estabeleceu novos critérios para permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, utilizando dois parâmetros semelhantes aos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para excepcionar a taxatividade do rol, nos seguintes termos:

"Art. 10. (...)

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." (NR)"

No caso concreto, o laudo emitido pelo médico hematologista que assiste a autora, é claro ao demonstrar a indicação dos medicamentos para a remissão da patologia e, assim, possibilitar o transplante de médula óssea, evidenciando a existência de estudos científicos que comprovam a eficácia do medicamento:

(...) ***Seu uso é já bem estabelecido nestes cenários e a droga é considerada segura e com boa chance de atingir o resultado esperado (remissão da doença), o que permitiria o tratamento curativo (transplante). Tal droga é utilizada em combinação, e, considerando a literatura disponível e os tratamentos utilizados, considero que o esquema Bendamustina, Gencitabina e Dexametasona (anexo) é o mais adequado para a paciente (literatura anexa)****. (1.8)*

Os estudos internacionais anexados aos autos também coadunam com a prescrição médica (1.12 1.13 1.14).

Assim, negar o tratamento apenas porque é *off label* - sem previsão de utilização específica em bula do medicamento - não se coaduna com o objetivo da nova legislação, mormente porque todas as medicações estão devidamente registradas e aprovadas pela ANVISA, ainda que para outro tipo de neoplasia.

Nessa senda, a procedência do pedido se impõe, inclusive, com a condenação da requerida ao ressarcimento da quantia de R$ 6.000,00 que a autora precisou desembolsar para o custeio do início do tratamento, conforme nota fiscal anexada ao evento 1, nota fiscal 7.

ISSO POSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:

a) tornar definitivos os efeitos da tutela deferida, condenando a requerida UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIVA MEDICA LTDA, a fornecer para a autora os medicamentos Bendamustina, Gencitabina e Dexametasona, na quantidade prescrita pelo médico, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias e

b) condenar a requerida a pagar para autora a quantia de R$ 6.000,00 a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo IGP-M a contar de 25/04/2023 e acrescida de juros legais de 1% a.m a contar da citação.

Sucumbente, arcará a requerida com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao procurador da parte adversa, estes fixados no percentual de 15% sobre o valor da causa, em observância ao artigo 85, §2º do CPC, corrigidos monetariamente pela variação do IGP-M a contar da data da fixação da verba e acrescidos de juros de mora de 1% a.m a contar do trânsito em julgado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, proceda-se a baixa.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIA HELENA CAMERIN, Juíza de Direito**, em 10/7/2023, às 10:54:1, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10041672184v2** e o código CRC **b8e46454**.